

1516365-21.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Crimes contra a vida

Magistrado: Leonardo Valente Barreiros

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 4ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... relatou que ostenta antecedentes por tráfico de drogas e porte de armas. Disse que a munição encontrada era para uso em ritual religioso. Admitiu sua participação no tráfico de drogas. Quanto à tentativa de homicídio do policial, negou qualquer participação ou envolvimento. Em juízo, voltou a negar os fatos, bem como o de outra acusação opor associação ao tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

4ª Vara do Júri

Compl. Jud. Crim. Barra Funda - Fórum Min. Mário Guimarães, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516365-21.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516365-21.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182984/2021 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 18909612 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 795/21/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 2182984 - 58º D.P. VILA FORMOSA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO FERNANDO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Valente Barreiros

Vistos.

FÁBIO FERNANDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c. c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, agindo com inequívoca intenção

homicida, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar o policial civil Neurailton Alves Ferreira, produzindo-lhe os ferimentos descritos em laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente aos autos, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, GUSTAVO DO CARMO ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c. c. artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima narradas, concorreu para a prática da tentativa de homicídio perpetrada em face de Neurailton Alves Ferreira, ordenando ao executor que matasse o ofendido.

Registram-se os principais atos e termo processuais: recebimento da denúncia em 26/07/2021 (fls. 122); recebimento do aditamento à denúncia em 16/08/2021, com a inclusão do denunciado Gustavo (fls. 157); citação dos réus (fls. 194 e 201); resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública (fls. 204/205).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou, com base nas provas produzidas no transcorrer da instrução processual, a pronúncia dos réus nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa propugnou pela impronúncia dos acusados.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A prova da materialidade com relação à pretensão punitiva concernente à tentativa de homicídio cometida contra a vítima Neurailton Alves Ferreira está evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 247/248.

Doutro lado, os indícios de autoria baseiam-se nos relatos da vítima, único a visualizar, por segundos, os responsáveis pelos disparos que o atingiram. Ninguém mais os viu. É o que se extrai dos depoimentos colhidos.

A vítima Neurailton Alves Ferreira (fls. 109/110 e 113), policial civil, durante as investigações, declarou que, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 12h, estava em serviço, juntamente com o policial civil Arthur Monteiro Gomes, quando receberam informações apócrifas a respeito da prática de tráfico de drogas com a equipe composta pelos policiais Agnaldo Neves Rocha e Priscila Viana Moraes, para o local mencionado nas informações. Neste local, foi realizada a apreensão do adolescente Vitor Alves Santana, que foi conduzido pela equipe de policiais composta por Agnaldo e Priscila a este DP. O depoente, juntamente com o policial Arthur, ainda no referido local, recebeu a informação de que parte da droga havia sido recentemente fornecida por um indivíduo, na Rua Maria Natauel, onde havia mais entorpecente e estaria o fornecedor. Rumaram para o local referido, onde, na altura do numeral 34, foi caminhando à frente, momento em que avistou três indivíduos a sua frente, na bifurcação da viela, um deles sentado, outro em pé na frente do primeiro, e o terceiro estava atrás de um poste. Ato contínuo, o indivíduo que estava abrigado atrás do poste saiu rapidamente, com um revólver em mão e, apontando em direção ao depoente, efetuou diversos disparos. O depoente, então, sentiu que foi atingido por um dos disparos e deu tempo de ver que o autor saiu correndo em fuga. O depoente deitou ao solo e foi socorrido pelo colega policial. O depoente descreveu o autor do disparo como sendo moreno, 1,77m de altura, magro, barba por fazer e cabelos enrolados. Trajava boné vermelho e calça jeans clara e abrigo de cor branca. No dia dos fatos, no próprio hospital, foi-lhe exibida a fotografia de um indivíduo que havia sido preso no local pela Polícia (Fábio, ora acusado), o qual reconheceu, sem sombra de dúvida, como sendo o autor dos disparos. Diante das informações que dispunha e por se tratar o local de ponto de tráfico, bem como, das circunstâncias em que se deram os fatos, afirmou que os três indivíduos que ali estavam na bifurcação estavam desenvolvendo atividade relacionada com o comércio ilícito de drogas, sendo que o indivíduo que efetuou os disparos funciona como “contenção”, isto é, pessoa que dá suporte para os traficantes que guardam a droga. Disse que os outros dois indivíduos se comunicavam com a pessoa de Fábio, o qual estava atrás do poste. Asseverou, ainda, que foi atingido justamente pelo motivo de ser policial e para evitar que efetuasse a prisão deles. Quanto às lesões sofridas, esclarece que o projétil atingiu a coluna, provocando fratura, e que estilhaçou, atingindo fígado e pulmão. Ouvido novamente pela Autoridade Policial (fls. 05/06, autos nº 1518693-21.2021.8.26.0228),

acrescentou que estava a uma distância de aproximadamente 3 a 4 metros dos indivíduos e teve uma boa visão da pessoa que estava sentada em frente ao poste e que essa pessoa olhou bem em direção ao declarante e que, em dado momento, tal indivíduo virou o rosto entre o poste e uma fresta e deu a ordem para o “contenção” (Fábio), dizendo “atira que é polícia”. Afirmou acreditar, portanto, que a pessoa que estava atrás do poste e atirou estava fazendo a segurança do tráfico, até mesmo da pessoa que estava sentada e lhe deu a ordem de atirar. Descreveu as características físicas desta pessoa que estava sentada, como sendo: homem, moreno, magro, cabelo curto, de rosto afinado. Convidado a realizar reconhecimento pessoal, em sala própria, onde estavam presentes diversas pessoas semelhantes, logrou êxito em reconhecer, com cem por cento de certeza, o acusado Gustavo do Carmo Almeida como sendo o indivíduo que estava sentado e deu ordem para o que estava em pé efetuar o disparo de arma de fogo que lhe atingiu, provocando-lhe as lesões sofridas. Em juízo, reconheceu com segurança o atirador, como sendo o número dois e o mandante, como sendo o número três, sendo eles Fabio e Gustavo, respectivamente. Antes do reconhecimento, o descreveu como pessoa magra, moreno escuro com cabelos crespos. Este, o atirador, era negro, mas não tão escuro. Visualizou melhor o partícipe, que estava sentado. Era magro com cerca de 1.80, moreno pardo, mais claro que o primeiro. Relatou que realizava diligências no local voltadas à prisão de suspeitos de tráfico de drogas. Em uma das vielas deparou-se com três indivíduos. Um deles sentado, que aponta com o réu Gustavo e outro atrás do poste. O primeiro disse “atira que é polícia”. Viu brevemente o que estava atrás do poste e este de imediato disparou. Tentou se abrigar e viu que os indivíduos correram. Que ao observá-los, estava em torno de três a quatro metros de distância deles. Que foi atingido por um disparo nas costas. Que lhe apresentaram as fotografias de algumas pessoas enquanto estava no hospital para fins de reconhecimento. Não sabe dizer se entre estas fotos estava a de Jonatan, pessoa baleada nas proximidades naquele mesmo dia. Recebeu informação de que identificaram os atiradores através de informações de populares. Que os outros policiais não viram o momento dos disparos. As fotografias lhe foram apresentadas algumas horas depois, quando estava no hospital. Foram enviadas algumas fotos via telefone, abordadas pouco tempo após o evento. Eram cerca de cinco fotografias, sendo que reconheceu apenas Fabio. Quanto a Gustavo, o reconhecimento foi pessoal, mais de um mês depois. Ele foi identificado por outra equipe. Reforçou que pôde ver melhor a pessoa de Gustavo.

A testemunha Agnaldo Neves da Rocha (fls. 07/09, 11 e 41/42), policial civil, em fase inquisitorial, relatou que estava em serviço, juntamente com o policial Neurailton, quando receberam informações apócrifas a respeito da prática de tráfico de drogas. Saíram, juntamente com a equipe composta pelos policiais Agnaldo e Priscila, para o local mencionado nas informações (Rua Hamamélis), conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas. Neste local, foi realizada a apreensão do adolescente Vitor Alves Santana, que estava exercendo a mercancia ilícita de drogas, sendo o adolescente conduzido pela equipe de policiais composta por Agnaldo e Priscila ao Distrito Policial. O depoente, juntamente com o policial Neurailton, ainda no referido local, recebeu a informação de que parte da droga havia sido recentemente fornecida por um indivíduo, na Rua Maria Natauel, local próximo, onde haveria mais entorpecentes e era possível encontrar o fornecedor. Desta forma, rumaram para o local referido e, na altura do numeral 34, havia diversas vielas, sendo que o policial Neurailton, que estava caminhando à frente, foi atingido por um disparo de arma de fogo, nas costas, caindo ao solo, não sabendo precisar de onde partiu o disparo. O depoente solicitou apoio, sendo o policial Neurailton socorrido por colegas ao PS do Hospital Santa Marcelina. Durante a ação, foi obtida a informação de que o possível autor do disparo seria a pessoa de João Victor Pereira Lima, o qual, em diligências imediatas, foi localizado em local próximo aos fatos, portando entorpecentes, anotações aparentemente relacionadas à venda de drogas e quatro aparelhos celulares. Não se localizou arma de fogo com João Victor. Em continuidade às diligências, momentos após o policial Neurailton ter sido baleado, receberam informações a respeito do autor dos disparos (com descrições físicas detalhadas) e que o mesmo era o “contenção”, ou seja, pessoa armada que dá

guardada ao traficante que fica na posse das drogas, sendo que tal indivíduo estava homiziado na mesma comunidade situada na Rua Maria Natauel, em um barraco usado para depósito de material reciclável, numeral 08. Desta forma, saíram em diligências até o local, onde lograram êxito localizar o referido indivíduo, o qual foi identificado como Fábio Fernando da Silva, sendo conduzido até o Distrito Policial. Em juízo, reiterou que não visualizou o momento dos disparos, mas apenas os ouviu. Deparou-se com a vítima Neurailton já caído, baleado. Esclareceu que outros colegas colheram as informações dando conta que João Vitor seria o atirador. Que retornou à comunidade e encontrou a pessoa que apontou João Vitor como atirador, informando o local onde ele residia. Na casa de João Vitor, ele admitiu a traficância mas negou os disparos contra a vítima. Depois, surgiram informações de que o atirador seria a pessoa de nome Fabio. Detido, ele foi fotografado e encaminharam as fotos para Neurailton. Tempos depois, colheu informações na comunidade de que o atirador não era Fabio, mas outro indivíduo identificado por policiais do 49ºD.P. Em contato com os colegas desta outra unidade, soube que com este outro foram localizadas munições do mesmo calibre daquelas utilizadas contra Neurailton. Outra equipe identificou Jonatan como outro que foi baleado na ocasião. Confirma que a vítima reconheceu por fotografia a pessoa de Fábio. Acredita que foram mostradas várias fotografias para a vítima. Não sabe apontar quem foram as pessoas que apontaram os nomes dos envolvidos. Que João Vitor foi o primeiro apontado na comunidade como sendo o atirador, mas indagado, negou veementemente, embora tenha admitido a traficância. Não se recorda se foi enviada fotografia de João Vitor para a vítima Neurailton. Fabio foi apontado também por pessoas da comunidade. Fabio também negou ter atirado contra o policial, tal como João Vitor. A negativa de Fábio deixou uma dúvida, pois este último admitiu que estava no local dos fatos, embora tenha voltado a negar. Acredita que Fabio teve medo de dizer quem era o autor dos disparos. No local onde deteve Fabio, haviam outras cinco ou sete pessoas. Todos foram fotografados e as fotos enviadas a Neurailton. Não sabe dizer se as fotografias foram encaminhadas com o apontamento de que Fabio foi apontado na comunidade como autor dos disparos. Não sabe dizer como a outra equipe identificou Gustavo como sendo o mandante do disparo.

A testemunha Arthur Monteiro Gomes (fls. 41/43), policial civil, no distrito policial, reiterou as informações prestadas por seu colega de farda, narrando que, durante diligências, o policial Neurailton foi baleado na comunidade situada na Rua Maria Natauel. Receberam, depois, a descrição física do autor dos disparos e a informação de que ele seria o "contenção", pessoa armada que dá guarda ao traficante que fica na posse das drogas. Saíram em diligências até o local apontado onde o tal indivíduo estaria, um barraco na mencionada comunidade, onde encontraram a referida pessoa, ora acusado, Fábio. Em juízo, esclareceu que não viu o fato. Ao se aproximar, a vítima já estava baleada no chão. Após socorrer a vítima, voltaram ao local e identificar uma pessoa de nome Vinícius, que traria a bolsa com as drogas, mas negou os disparos. Mais tarde, receberam a informação que o atirador seria Fabio, e no local onde ele estava, haviam cerca de cinco homens e foi feita a fotografia de todos os presentes no local e encaminhada para Neurailton, que de pronto, reconheceu Fabio. Que informações anônimas apontavam que as pessoas envolvidas em ocorrências policiais na região costumam se esconder em uma reciclagem, onde localizaram Fabio. Quando da incursão, não visualizou o atirador. Esclarece que a pessoa que chamou de Vinícius é na verdade João Vitor. Não houve qualquer disparo por parte da equipe. Soube que Gustavo foi detido por outro distrito policial, desconhecendo os detalhes.

A testemunha Jonathan de Oliveira da Silva (fls. 102), em sede policial, relatou que, na data dos fatos, havia ido à comunidade Barroca para adquirir drogas. Havia acabado de comprar uma porção de crack e, ao iniciar a subida da rua para ir embora, logo que virou a rua, em uma curva, sentiu na hora ter sido atingido por um disparo de arma de fogo em sua coxa direita e, após, escutou diversos tiros e muita correria. Não sabia o que estava acontecendo. Populares acionaram o socorro, sendo levado ao hospital. Alegou que, em relação ao disparo, não viu nada, mas relatou que, em conversa com diversas pessoas, todos afirmaram que a munição aparentava ser calibre 22. Em relação à porção de entorpecente que havia acabado de adquirir,

ratificou que é usuário e que nunca traficou drogas, que trabalha com reciclagem. Exibida a fotografia de Fábio, preso em flagrante, informou que já viu ele na "Gamelinha", local em que ficam diversas pessoas usando drogas. Disse que, na data dos fatos, não viu ele na comunidade Barroca, e que não tem amizade com ele. Em juízo, as partes desistiram de sua oitiva.

O acusado Fábio Fernando da Silva (fls. 15), interrogado pela Autoridade Policial, resolveu exercer seu direito de permanecer em silêncio. Em juízo relatou que naquele dia mal conseguia andar por conta de alguns furúnculos que tinham na perna. Que trabalhou com reciclagem naquele dia e à noite policiais estiveram no local em que trabalhava com reciclagem. Que eles entraram com sua autorização, foram embora e mais tarde retornaram. Pediram para que os acompanhasse até a Delegacia, com o que concordou. Que ele deveria ir para um "reconhecimento". Na delegacia perguntaram se sabia quem trocou tiros pela manhã, e negou conhecimento sobre tais fatos. Que insistiram que saberia quem eram os atiradores e se não colaborasse seria apontado como o atirador. Assim, até hoje se encontra preso. Negou envolvimento com o tráfico de drogas. Que faz reciclagem no terreno onde reside. Que não presenciou o episódio que vitimou o policial, apenas os comentários. Que realmente tiraram fotografias de todos os que estavam no local onde foi abordado. Os policiais apenas mencionaram que havia uma denúncia anônima.

O acusado Gustavo do Carmo Almeida (fls. 16, apenso 1518693-21.8.26.0228), ouvido pela Autoridade Policial, na presença de seu advogado, relatou que ostenta antecedentes por tráfico de drogas e porte de armas. Disse que a munição encontrada era para uso em ritual religioso. Admitiu sua participação no tráfico de drogas. Quanto à tentativa de homicídio do policial, negou qualquer participação ou envolvimento. Em juízo, voltou a negar os fatos, bem como o de outra acusação opor associação ao tráfico que suporta. Que não conhece qualquer dos envolvidos. Quando foi preso, na sua casa, o policial Ricardo tirou fotografias suas e enviou ao policial Neurailton. Foi absolvido no episódio em que os policiais lhe prenderam em flagrante em sua casa, ocasião em que tiraram as fotografias. Que nesta ocasião nada de ilícito encontraram em sua casa, e apenas na Delegacia surgiram as munições, e que foi absolvido de tais imputações porque nada disso foi provado. Que ao ser levado À Delegacia, participou de um reconhecimento pessoal no qual foram colocados ao seu lado dois policiais, mais altos que si.

Analisando o reconhecimento judicial, a vítima apontou o acusado Fábio como sendo o atirador e Gustavo, como o que, sentado, deu a ordem: "atira que é polícia". Contudo, por ser o único indício quanto à autoria delitiva, já que não há mais nada que coloque os réus na cena do crime, deve ser avaliado com a devida cautela. Sabidamente, o reconhecimento pessoal é meio de prova que exige extremo cuidado, ante os diversos estudos sobre "falsas memórias" que indicam que sua segurança, pode, a depender do caso concreto, estar comprometida. Não por outro motivo, preleciona Nucci que: "Quanto ao reconhecimento feito em juízo, é prova direta, mas subjetiva e merecedora de análise criteriosa (...). Além disso, é preciso contar com o fator de deturpação da memória, favorecendo o esquecimento e proporcionando identificações casuísticas e falsas". (Código de Processo Penal comentado, 12ª Ed, pág. 539).

Partindo desta premissa, que a nosso ver deve nortear o julgador na valoração desta prova, não se pode olvidar de alguns aspectos que influenciam, neste caso concreto, o convencimento do julgador.

A vítima Neurailton, em seu depoimento, deixa claro que tudo aconteceu muito rapidamente. Caminhando pela viela, à frente do grupo de policiais que o acompanhava, vencida determinada sinuosidade, avistou três pessoas próximas ao que parecia ser um poste. Afirma ter visualizado, com maior nitidez, o que estava sentado defronte ao poste e que deu a ordem para que fosse feito o disparo. Esta pessoa, reconheceu como sendo o acusado Gustavo. Na sequência, de trás do poste, surge outro indivíduo que de imediato inicia os disparos, fazendo com que a vítima, por puro e natural instinto de sobrevivência se jogasse para o lado, em busca de abrigo. Neste momento, foi atingida por um disparo nas costas. Nesta fração de segundos, pode ver que o atirador era, tal como descreveu momentos antes do reconhecimento, em observância ao disposto no artigo 226, inciso I, "como pessoa

magra, moreno escuro com cabelos crespos". E acrescentou: "Este, o atirador, era negro, mas não tão escuro. Visualizou melhor o partícipe, que estava sentado". Aqui o primeiro dado que chama atenção. Chamado a descrever o atirador, o indica como negro, embora não tão escuro. O réu Fabio não é pessoa negra, mas sim parda. E nem se está a exigir da vítima absoluta fidedignidade. Por óbvio, naquele momento sua preocupação era salvar sua vida dos disparos que certamente buscavam a atingir e de fato a atingiram com notória gravidade. Contudo, tal fato também indica que a visão que teve do atirador estava comprometida, não apenas pela velocidade dos acontecimentos, mas também pelo fato de seu agressor estar atrás de um poste, utilizando um boné.

Todavia, até aqui, poder-se-ia considerar, especialmente porque nesta fase não se exige certeza de autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, que mesmo descrevendo o atirador como pessoa de cútis distinta, sua convicção em apontar Fábio deveria ser merecedora de crédito, com a consequente submissão do caso ao Conselho de Sentença. Ocorre que a instrução demonstrou que a vítima teve contato com fotografia do acusado, de forma absolutamente informal e fora dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, fazendo pairar a dúvida se, ao apontar, em Juízo, a pessoa de Fábio, o fez por se recordar da fotografia visualizada, ou porque de fato sua memória buscou o momento dos acontecimentos. Se presente a primeira hipótese, o reconhecimento efetuado em Juízo não se presta sequer para fins de decisão de pronúncia.

É dos autos que após o fatídico evento, equipes buscaram pela comunidade informações sobre possíveis envolvidos no atentado contra a vida do policial. Segundo as testemunhas ouvidas, informações apócrifas apontaram, de início, uma pessoa de nome João Vitor como sendo atirador. Em contato com tal suspeito, o policial Agnaldo Neves da Rocha, conforme relatou, colheu que: "indagado, negou veementemente, embora tenha admitido a traficância. E acrescentou: Não se recorda se foi enviada fotografia de João Vitor para a vítima Neurailton.

Conforme se nota, apontado por populares, João Vitor deixou de ser suspeito, segundo o policial Agnaldo porque negou veementemente.

Mais tarde, convencido que João Vitor não estava envolvido nos fatos aqui apurados, continuou suas incursões e da mesma fonte (denúncias anônimas) colheu que o atirador seria a pessoa de Fábio. Conforme relatou na sequência de seu depoimento: "Fabio foi apontado também por pessoas da comunidade. Fabio também negou ter atirado contra o policial, tal como João Vitor. A negativa de Fábio deixou uma dúvida, pois este último admitiu que estava no local dos fatos, embora tenha voltado a negar (os disparos). Acredita que Fabio teve medo de dizer quem era o autor dos disparos".

O que se nota do depoimento da testemunha Agnaldo, primeira pessoa a identificar Fábio como o atirador, é que embora este tenha negado, tal como João Vitor o fez, sua negativa não o convenceu. Tanto assim que tirou fotografia de Fábio, e de outras pessoas que o acompanhavam, e enviou para a vítima, que acabara de ser hospitalizada. Quanto a João Vitor, afirmou que não se recorda de ter tirado fotografias e que sua negativa o convenceu na medida em que ele teria admitido à traficância no local. Por tal razão, este Juízo o questionou sobre os motivos de ter descartado a suspeita que pairava sobre João Vitor ante sua mera negativa e não ter descartado igualmente a suspeita que pairava sobre Fábio, se esta também negou, especialmente pelo fato de as suspeitas terem sido levantadas pela mesma fonte (denúncias anônimas na comunidade). Segundo o policial, suspeitou de Fábio porque acreditou que ele sabia quem era o atirador mas teve medo de dizer.

O que preocupa é que, está a parecer que o policial Agnaldo tenha suspeitado não de que Fabio tenha atirado, mas sim que ele sabia quem tinha atirado e que assim não quis colaborar. Algo muito diferente de ser ele próprio (Fábio) o atirador. Tal impressão, que emerge da narrativa de Agnaldo, vai de encontro ao relatado por Fabio em seu interrogatório. Este, afirmou que insistiram que saberia quem eram os atiradores e se não colaborasse seria apontado como o atirador. Ao que parece, foi mesmo o que aconteceu.

A partir daí, fotografias suas foram enviadas, junto com outras cinco ou seis, à vítima Neurailton, que no hospital, com um ferimento causado por disparo de arma de

fogo nas costas e assim sabe-se lá em que condições, apontou Fabio como sendo o atirador. Este teria sido o primeiro contado da vítima com a imagem de Fábio, em total desconformidade com os postulados do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isto porque não se sabe se as outras fotografias mostradas eram de pessoas que guardavam alguma semelhança com o réu, se houve algum direcionamento, já que realizado por aplicativo de telefone celular e Fábio, àquela altura, era o único suspeito (João Vitor já estava descartado e parece que nenhuma fotografia dele foi enviada), e estando a vítima hospitalizada, possivelmente sendo preparada para uma cirurgia certamente delicada.

Neste ponto, impossível descartar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 179.682-3/SC, em 27/10/2020, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz. No referido aresto, estabeleceu-se a obrigatoriedade da estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, “cuja formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime”. E foi além, assentado ainda que: “À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo”. Veja-se que, mais do que as conclusões do julgado, a indicar que o reconhecimento no presente caso está eivado de nulidade, preocupa-me sobremaneira as premissas estabelecidas pelo STJ para se chegar a tal solução. É que da ementa do julgado extrai-se valiosas lições de como o reconhecimento fotográfico pode levar a sérios e irreparáveis erros judiciais. Neste sentido, segue trechos da emenda que interessam ao caso em testilha:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

(...)

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

Todos os elementos fáticos trazidos aos autos, aliados à conclusões recentes dos Tribunais superiores e especialmente as premissas estabelecidas tal como consta no referido julgado, indicam que não há qualquer segurança de que a vítima, ao reconhecer Fábio em Juízo, tenha se recordado do momento dos fatos, sendo muito mais provável que tenha se recordado da fotografia que lhe foi enviada, certamente por ele vista em diversas outras oportunidades até o dia da audiência.

Outrossim, o caso do acusado Gustavo não é diferente. Embora os relatos colhidos neste autos indiquem que a vítima Neurailton, ao contrário do ocorrido em relação à Fabio, não tenha tido qualquer contato prévio com a fotografia do acusado em desconformidade com os preceitos do artigo 226, mas o tenha reconhecido apenas presencialmente em solo policial, pouco mais de um mês depois dos fatos, não é o que se extrai do que foi dito nos autos que tramitaram na 6ª Vara Criminal Central,

sob número 1518684-59, sobre os fatos imputados a Gustavo quando da ocasião de sua prisão. É que, tal como mencionado pela Defesa, naqueles autos há o relato da testemunha Ricardo, tal como constou às fls. 170 da sentença de absolvição Gustavo dos delitos de associação para o tráfico de drogas e porte de munição: “Apenas a testemunha presenciou o reconhecimento da vítima de tentativa de homicídio feito através de um celular, de forma informal, ainda no local dos fatos”.

Verifico assim, que, também aqui, houve um primeiro reconhecimento por fotografia, enviada através de um celular para a vítima, apenas com a fotografia de Gustavo, fato este que foi omitido nestes autos.

Ademais, dos autos que tramitaram na 6ª Vara se extrai ainda que a única munição que poderia ser vinculada a Gustavo foi um projétil de calibre 38, não sendo este dado apto a fazer concluir que ele teria dado a ordem para o disparo. Até porque, mais coerente seria que a munição tivesse sido encontrada em poder do atirador, o que não foi o caso.

Noutro giro, superada a questão da absoluta precariedade dos reconhecimentos elaborados nestes autos, único indício de autoria havido contra ambos os acusados, resta aferir se, ao menos para fins de pronúncia, onde não se exige grau de certeza, eles seriam aproveitáveis.

Neste sentido digo que não é de hoje que doutrina e jurisprudência tem se inclinado em afirmar que o brocardo *in dubio pro societate* não possui substrato legal ou constitucional, sendo criação doutrinária e jurisprudencial que, por si só, ante a ausência dos requisitos legais, não enseja a pronúncia. Sobre o mencionado princípio vale, mais uma vez, por oportuno, mencionar preciosa lição do Desembargador paulista Guilherme de Souza Nucci:

“A expressão *in dubio pro societate* (na dúvida, em favor da sociedade) é mais didática do que legal. Não constitui um princípio do processo penal, ao contrário, o autêntico princípio calca-se na prevalência do interesse do acusado (*in dubio pro reo*)”. (Código de Processo Penal Comentado, 12ª Ed. Pág. 814).

Ademais, não há nenhum ganho para a sociedade a submissão de um acusado, sem os suficientes indícios de autoria, conforme determinação legal, ao julgamento pelos seus pares, tangenciando assim com uma possível injustiça.

Baseado em semelhantes premissas, em março de 2019, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar Agravo no Recurso Extraordinário 1.067.392/CE entendeu que o brocardo *in dubio pro societate* não seria critério legítimo a fundamentar reforma de sentença de impronúncia.

Ao analisar o julgado, Gilmar Ferreira Mendes ensina que: “apresenta relevantes contribuições para o aprimoramento do sistema penal brasileiro, especialmente em matéria penal, a partir de dois prismas: da necessidade de uma teoria de valoração racional da prova penal; e do *standard probatório* para a decisão de pronúncia, junto a incongruência do *in dubio pro societate*”. E mais adiante arremata:

“(…) percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto princípio *in dubio pro societate*, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova. Além de desfocar o debate e não apresentar base normativa, o *in dubio pro societate* desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a decisão de pronúncia”. (Curso de Direito Constitucional, 16º Ed. Pág. 618).

O que se verifica, conforme moderna doutrina e jurisprudência, é que os indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a decisão de pronúncia devem ser extraídos a partir de uma valoração da prova orientados por critérios de lógica e racionalidade. Não por outro motivo o legislador estabelece, dentro do sistema bifásico, um sumário da culpa, onde o juiz deve, atento a prova ali produzida, remeter ao julgamento popular apenas os casos onde dali se extrai indícios calcados em provas alicerçadas em elementos empíricos seguros e em conformidade com os ditames legais. Do contrário, a impronúncia será de rigor.

No presente caso, além do reconhecimento pessoal, único indício de autoria existente contra os réus, estar precedido de um reconhecimento fotográfico

claramente em desconformidade com os requisitos legais minimamente estabelecidos, aliado ao fato de ter a vítima descrito o atirador com negro, enfraquecem por demais tais indícios.

Não obstante, quando do envio da fotografia de Fabio para a vítima (esta na iminência de ser lavada a um centro cirúrgico), havia sobre ele a suspeita do policial Agnaldo, baseada, segundo por ele dito, no fato de Fábio confirmar que estava no local dos disparos sem contudo ter apontado quem seria o atirador. Tal suspeita traz dúvida se, ao enviar as fotos para a vítima (de Fábio e outras cinco ou seis pessoas) não o fez com algum direcionamento em relação ao réu. Não bastasse, após a prisão de Fabio, nenhum reconhecimento pessoal foi realizado pela autoridade policial.

Quanto a Gustavo, a fragilidade é a mesma. Embora omitido nestes autos, é fato que, antes de elaborar o reconhecimento pessoal em relação a este, a vítima também recebeu fotografia dele via aparelho celular, e agora sem notícias de que outras de pessoas distintas lhe foram remetidas conjuntamente.

Mais uma vez, inviável desconsiderar o peso que tais fotografias, enviadas sem qualquer critério e eventualmente com algum sugestcionamento, pode ter exercido no reconhecimento elaborado em Juízo. A dinâmica dos fatos autoriza crer que a vítima pouco pôde ver de seus algozes, sendo muito provável que sua memória esteja direcionada muito mais às fotografias dos réus (fotografias tiradas quando não havia qualquer motivo sério para serem apontados como suspeitos), do que a fisionomia do atirador e seu mandante, que a esta altura, não se pode, ainda que indiciariamente e para fins de decisão de pronúncia, admitirmos ser Fábio e Gustavo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, para IMPRONUNCIAR os réus FÁBIO FERNANDO DA SILVA e GUSTAVO DO CARMO ALMEIDA das imputações que lhes foram feitas.

Outrossim, em virtude do ora decidido, revogo a prisão preventiva decretada contra os acusados. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA